

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：勞動社會法

第一題

【總題說明】

在憲法社會國原則之適用下，有關消極勞動市場政策措施之核心制度之一：就業保險（有些國家稱之為失業保險）制度，作為社會法之生存照管的典型社會保險法制，其中的關鍵子制度：失業給付，針對非自願離職之失業者，給予原則上最多六個月之薪資替代給付，即所謂失業給付，在各國法制中——我國就業保險法亦不例外，並非建制為單純的、無任何條件與附帶義務，相反的，在積極性勞動市場政策之同時作用下，失業者之「積極尋職」、「接受公立就業服務機構之工作推介」，成為失業給付的標準配備。本題之設計，即針對前述相關問題，包括再失業認定、推介就業之可期待性，乃至於失業給付所可能涉及之違反誠實信用的行政行為、行政指導、社會給付競合、社會給付補充性原則等附帶問題，考驗考生之理解與實務操作能力。

【評分要點】

第(一)子題

就業保險法第15條搭配同法第13條，明令得請領失業給付之失業者，有接受公立就業服務機構推介工作之義務，如為可期待失業者接受之工作，而遭拒絕者，就業保險人得拒絕全部或一部之失業給付，學理上一般稱之為「可期待性原則」(Prinzip der Zumutbarkeit)。依據此原則，失業給付並非失業者無條件得以享有之權利，特別在工作福利(Workfare)的思維下，即便在法定6個月的得請領失業給付期間，失業者仍有積極尋職之義務，特別是接受公立就業服務機構所推介「可期待其接受的工作」，否則即有喪失失業給付請求權之可能。學說及實務上，關於何謂符合其工作能力之僱用，如未存在一般或其個人特殊事由認不可期待其接受者，均屬可期待，常見一般事由如：所推介之工作違反法律或勞動保護相關規定，而常見之個人特殊事由，如推介工作之工資低於就業保險投保薪資，考量相關之費用支出後低於所得請領之失業給付，或通勤上下班時間不符

比例原則的過長（如距離過遠，就業保險法第 13 條第 2 款即為適例）。此外，如推介之工作為定期契約，或是失業者必須暫時放下原先負責之家務，或非屬失業者原本所受之職業教育訓練或至今所行使之主要職務者，是否仍屬可期待失業者接受？不無爭議，惟實務上多肯定之，應認可期待失業者接受。本題相關事實，即屬失業者期待從事原本職業教育訓練的職種，但公立就業服務機構所推介之工作，雖有所不同，但應可期待其接受，A 拒絕依囑前往面試，公立就業服務機構扣減其一部分、非更不利的全額扣減失業給付，應屬對相對人更為有利的手段，可資接受。當然，考生亦可針對「是否得堅持失業者個人工作意願」，而得合理行使拒絕推介「不合理」、「無法期待失業者接受」之工作？做必要的發揮，但根據題意，比較偏向不同的理解，方屬正確。

第(二)子題

依本題事實，當事人主張如無失業給付之支持，將明確陷入生活困頓，難以為繼，公立就業服務機構除重申務必參加面試之意旨外，同時勸誘到：如真遭停發失業給付，應有其他救助型之特殊短期生活津貼可申請，以解燃眉之急。此時應屬單純之觀念通知，尚未達「以準備將來作為或不作為特定行政行為目的」之行政指導，是 A 得否請領其他救助型生活津貼，必須依循其他相關法律規定，並不以公立就業服務機構之承諾為基礎，該所謂「承諾」亦應認不成立公法上的保證。當然，考生亦可在此發揮，主張構成違反誠實信用之行政行為、不作為，本題刻意未提供所謂其他特殊短期生活津貼之具體敘述，亦即保留考生發揮之空間。

第(三)子題

如前所述，就業保險法第 15 條作為社會保險給付領域中（在此：就業保險），可期待性原則的具體化，作為相對人請求特定公法上給付之協力義務，「要求失業者應積極尋職」之目的應屬正當，規範特定之程序義務（如參加諮詢、面試），乃至於認定是否屬可期待失業者接受推介之工作，尚未違反比例原則，應屬合憲。憲法社會國原則的實現，旨在均衡社會的不平等，維繫人們有尊嚴的生存，但並未禁止課予相對人一定的協力或其他行為義務，只要無違比例原則。失業給付，制度上屬於「消弭過渡期間之經濟困頓」的消極勞動市場政策措施，重點在於勞動市場上的供需調和，以此出發，要求失業者積極尋職，應屬正當，即便在個案的具體適用上，如屬不可期待失業者接受推介之工作，公立就業服務機構應

不得任意扣減給付，因而恐有違法問題，但就業保險法系爭規定，並未違憲。

【閱卷委員的話】

本題之主要考點為工作福利，亦即就業保險被保險人請領失業給付，依法負有協力義務，原則上應接受公立就業服務機構推介之工作，或其安排之就業諮詢與職業訓練，除非就各該工作或安排對於被保險人而言，係屬不能期待其接受（亦即各該工作或安排具有可期待性）。就業保險法第 13 條與第 14 條之規定，係可期待性原則之具體化，第 15 條則係其違反之法律效果規定。工作福利措施所體現之價值決定為社會法上之補充原則，亦即一方面要求個人應自我負責，另一方面強調國家之協助角色。換言之，國家雖提供社會給付，但社會政策之政策目標在於協助個人自立，從而一方面提供給付，另一方面也有所要求——亦即賦予受協助者配合促使其回到職場之協力義務。本題第（一）子題以及第（三）子題之作答，尤其第（三）子題之作答，與此高度相關。不過，絕大多數考生對於工作福利與補充原則都相當陌生，無法深入分析，因此難以獲得高分。

第（二）子題相對簡單，主要考公立就業服務機構之「承諾」是否構成公法上之保證。由於其他救助型之特殊短期生活津貼仍有其要件，行政機關須依法行政，公立就業服務機構之表示在解釋上難以認定為「承諾」。就此一部分，考生作答情形明顯較佳。

第二題

【總題說明】

本題旨在測驗應考人對於工會法所訂之工會組織類型、工會成立與組織變更等相關規範的理解。由於企業工會依法以廠場、事業單位、關係企業或金融控股公司為範圍之組織，企業若以分割方式而變動組織，將對於企業工會組織產生影響，為避免工會運作及勞工結社權因企業分割亦因而受影響，企業工會得經由議決而分立以成立子公司企業工會，使移轉至新成立子公司之會員繼續行使既有之工會相關權利，不受工會法第 11 條第 1 項連署發起門檻 30 人之限制。分立後之子公司企業工會得依勞動法令推派（選）法定代表，包含依勞資會議實施辦法第 5 條規定為勞資會議之勞方代表選舉事宜，若事業單位未能認識上述規範，否認分立後之子公司企業工會之工會地位，逕自辦理勞資會議勞方代表之選

舉，將導致該工會得辦理勞資會議勞方代表選舉之事務活動遭剝奪，對於工會活動產生不當影響，從而可能構成不當勞動行為。

【評分要點】

第(一)子題

1. 依工會法第 26 條第 1 項第 3 款之規定，工會之分立應經會員大會或會員代表大會之議決。若工會議決為分立，依工會法施行細則第 33 條規定：「工會因分立，而成立新工會者，應依工會法第 11 條規定辦理。但不須連署發起及辦理公開徵求會員。」因分立而成立之新工會，係以有其原有會員為基礎，爰無須組成籌備會辦理公開徵求會員，惟仍應依工會法第 11 條規定，擬定新工會之章程及召開成立大會，檢具應備文件向主管機關辦理登記。
2. 企業工會因事業單位依法進行分割，原企業工會會員亦因企業分割而移轉至新成立之子公司時，為使移轉至新成立子公司之會員繼續行使既有之工會相關權利，原企業工會從而分立而成立子公司企業工會，縱新成立子公司之勞工人數未達 30 人，因分立而成立子公司企業工會係以有其原有會員為基礎，即不受工會法第 11 條第 1 項連署發起門檻 30 人之限制，以避免工會運作及勞工結社權因企業分割而受影響。此意旨亦可參勞動部 111 年 04 月 11 日勞動關 1 字第 1110136268 號函：「為避免工會運作及勞工結社權因企業分割而受影響，如企業所進行之分割，將原企業工會會員移轉至新成立之子公司，該子公司勞工人數未達 30 人，則原企業工會得依上開工會法規定，議決分立成立子公司企業工會，不受工會法第 11 條第 1 項連署發起門檻 30 人之限制。」
3. 本題中，乙公司將其 A、B、C 部門分別分割為新設之 A 公司、B 公司與 C 公司，亦即將本屬單一法人之乙公司分割為不同法人格之 4 家公司，並將原 A、B、C 部門員工分別留用至 A、B、C 三間公司，惟每家公司之員工人數均未逾 30 人，依上開工會法之規定暨為避免工會運作及勞工結社權因企業分割而受影響，落實保障勞工團結權之意旨，甲工會在符合工會法第 26 條第 1 項第 3 款之規定，於 112 年 1 月 14 日經會員大會決議通過分立成立 A 工會即不受工會法第 11 條第 1 項組織工會應有勞工 30 人以上之連署發起之限制，主管機關核發立案證書乃屬合法。

第(二)子題

1. 按勞資會議實施辦法第 5 條第 1 項前段規定：「勞資會議之勞方代表，事業單位有結合同一事業單位勞工組織之企業工會者，於該工會會員或會員代表大會選舉之……。」，可知勞資會議之勞方代表，事業單位有結合同一事業單位勞工組織之企業工會者，於該工會會員或會員代表大會選舉之，僅事業單位中無結合同一事業單位勞工組織之此類工會時，始得由事業單位依該辦法第 5 條第 2 項規定自行辦理勞資會議勞方代表選舉事宜，合先敘明。承上題，A 工會為合法成立之企業工會，且經主管機關核發立案證書，已如上述，其係以自己公司分割而設立之 A 公司為工會組織範圍，符合勞資會議實施辦法第 5 條第 1 項所規定「勞資會議之勞方代表，事業單位有結合同一事業單位勞工組織之企業工會者，於該工會會員或會員代表大會選舉之」，則選舉勞資會議勞方代表，即屬 A 工會之會員代表大會或會員大會之職權，不因其為分立所成立之企業工會而影響其相關權利之行使。
2. 又工會活動，並不以工會會員大會、會員代表大會、理監事會所議決之活動為限，即使是工會會員為維護、提升勞工之勞動條件為目的，依循工會之運動方針所為之行為，應認屬工會活動而受法律之保護（最高行政法院 110 年度上字第 242 號行政判決參照）。對於有權能辦理勞資會議勞方代表選舉之工會，辦理勞資會議勞方代表選舉即屬工會法第 5 條第 11 款所規定：「工會之任務如下：…十一、其他合於第 1 條宗旨及法律規定之事項」，此關於工會任務之規定，係屬工會活動。若事業單位逕自辦理勞資會議勞方代表之選舉，將導致企業工會原先得辦理勞資會議勞方代表選舉事務之工會活動權利遭剝奪，對於工會組織與運作將產生不當影響，甚至可能致使工會會員或員工對參加人或參與其活動之合法正當性產生質疑，原則上即構成工會法第 35 條第 1 項第 5 款之不當勞動行為。

【閱卷委員的話】

本題可說是相當容易作答的一題，尤其在相關條文皆已檢附給考生的情況下。

在第(一)子題的部分，考生只要引用工會法第 26 條第 1 項第 3 款的規定（工會應經會員大會或會員代表大會之議決分立）以及工會法施行細則第 33 條規定（工會因分立，而成立新工會者，應依工會法第 11 條規定辦理。但不須連

署發起及辦理公開徵求會員)；並論述在前述規定下，為避免工會運作及勞工結社權因企業分割而受影響，分立成立之新工會，原企業工會會員移轉至新成立之子公司，該子公司勞工人數即使未達 30 人，原企業工會仍得依上開工會法規定，議決分立成立子公司企業工會，不受工會法第 11 條第 1 項連署發起門檻 30 人之限制，即可獲得相當不錯的分數。

在第(二)子題的部分，考生若有論及依勞資會議實施辦法第 5 條之規定，工會具有權能辦理勞資會議勞方代表選舉，此乃工會法第 5 條第 11 款所規定(工會之任務如下：…十一、其他合於第 1 條宗旨及法律規定之事項)；又事業單位有結合同一事業單位勞工組織之企業工會者，勞資會議勞方代表應由該企業工會會員或會員大會選舉之；若無此類工會，始得由事業單位依該辦法第 5 條第 2 項規定自行辦理。若事業單位逕自辦理勞資會議勞方代表之選舉，將導致企業工會原先得辦理勞資會議勞方代表選舉之事務活動遭剝奪，對於工會活動產生不當影響，故原則上構成工會法第 35 條第 1 項第 5 款之不當勞動行為。前述的論述與作答即可獲得相當不錯的成績。

即使本題涉及之爭議並不複雜，又有檢附相關規定的條文，考生只要適用相關規定到本題的事實，幾乎就可以獲得相當不錯的分數，但仍有部分考生無法將相關規定對應到本題之事實，顯示對本題所涉及之爭議欠缺概念，因此即使有條文也不知如何引用。

第三題

【總題說明】

針對業界常見之所謂禁止挖角協議：存在於不同的、通常處於一定競爭關係的企業間，針對特定範圍之勞工，企業彼此承諾「不為挖角」(不論所列舉與涵蓋的法律關係與契約形式為何)，直接間接有害於特定勞工職業自由權之行使。觀察針對禁止挖角有明文規範或有明確法官法形成之國家，多未完全加以禁止，而是在一定的規範性框架與範圍內，認仍有合法之可能，最關鍵的規範性典範即為勞動法之競業禁止、不正競爭禁止、企業併購之勞工移轉等適用原則。我國雖無明文規定，司法實務上亦極為罕見，但考生得運用與禁止挖角協議相關之其他「勞動法典範」：競業禁止、不正競爭禁止、企業併購之勞工移轉，加以具體運用及發揮。

【評分要點】

第(一)子題

契約約定禁止惡意挖角條款，以保護企業經營利益，並非法律所不許。惟基於憲法基本權之第三人效力，或說：國家保護職業自由基本權之國家保護義務，應注意有關職業自由、工作權不得遭受違憲的侵害。企業如為保護營業秘密與正當營業利益，限制員工工作權，性質上類似離職後競業禁止約定，應嚴格加以審查，應依勞動基準法第 9 條之 1 所揭櫫之基本原則，如約定限制工作權之合理期間、區域、職業活動，並提供相當補償，以調和勞工權益與企業利益。就本題而言，原本應得採取較輕微之限制手段，即可達企業利益維護之目的，系爭約定範圍，實有過度寬鬆擴張之虞，所生過度侵害所涉勞工職業自由，難以正當化。再者，金融機構在遵循法令或規避風險上會有一定之要求，若投標銀行相對保守，在招攬員工時，將會以最嚴格之方式選擇不予錄用任何 A 金融集團消金業務員工，以避免風險，都將直接間接惡化相關勞工的職業自由行使。是以，A 金融集團保密合約禁止不當招攬約定，已經影響員工職業自由，或說工作權及擇業自由，應運用類似的規範性內涵控制，即競業禁止制度，加以嚴格審視，此約定應非適法，應認不生效力。在此，考生應得以盡力關照與禁止挖角協議相關之其他勞動法典範，特別是競業禁止、不正競爭禁止、企業併購之勞工移轉等，彼此關照援引，進行必要的契約內容控制，而非較為政治正確般的，僅以「有害勞工權益」就簡略地否定其一定範圍內的合法可能。

第(二)子題

系爭「禁止不當招攬約定」，其內容與涉及範圍確實過度廣泛，已逾越「作為不當行為禁止」之意圖，至少形式上。想像上，系爭約定可能本於不同目的：目的—，禁止營業讓與之繼受者，直接承受原有勞動關係的移轉，違反營業讓與、企業併購之勞動關係移轉原則（作為法律典範），也形同掏空所謂商定留用權，應為此約定直接違法而無效之結論。目的二，保障「出售消金業務之契約準備階段的公平性」，確保投標者間之競爭平等，則在僅適用於競標期間、確保投標者競爭平等之目的性限制、針對引起不正競爭結果之具體情形（如存有當事人之特定行為）等條件下，約定得以合法，但必須進入契約履行之控制階段，亦即約定本身尚屬適法，但具體情狀下的履行結果，仍可能違法。目的三，避免「其他未得標廠商之挖角招攬原消金業務從業員工」，藉以保障「最後得標廠商之利益」，

違反競業禁止（作為法律典範），應為此約定直接違法而無效之結論。準此，如針對投標期間，有阻止不正競爭之正當效果，既不會讓事實上成立之勞動關係（A集團所屬員工與投標者）失之無效，則應認在此特定範圍內，約定本身合法，雖嗣後仍有履行違法之可能性。在此，如同前述，考生應得以盡力關照與禁止挖角協議相關之其他勞動法典範，特別是競業禁止、不正競爭禁止、企業併購之勞工移轉等，彼此關照援引，進行必要的契約內容控制，而非較為政治正確般的，僅以「有害勞工權益」就簡略地否定其一定範圍內的合法可能，特別是第二子題部分的「不正競爭防止」，在投標階段內，應能觀察到此合理利益之特殊性。

【閱卷委員的話】

本題評量之關鍵概念在於「禁止挖角協議、競業禁止、不正競爭禁止、企業併購之勞工移轉」，相較於第二題，本題的難度較高，因此大多數考生在這題的表現沒有第二題好。

雖然本題難度較高，但大多數考生在第（一）子題的部分，還是有論及禁止挖角協議涉及競業禁止的問題，只是深入論述之考生並不多。契約約定禁止惡意挖角條款以保護企業經營利益，並非法所不許，但有關職業自由、工作權仍不得遭受違憲的侵害。企業如為保護營業秘密與正當營業利益，限制員工工作權，性質上類似離職後競業禁止約定，應嚴格加以審查，亦即應依勞動基準法第9條之1所揭櫫之基本原則，如約定限制工作權之合理期間、區域、職業活動，並提供相當補償，以調和勞工權益與企業利益。因此，第（一）子題的情形原本得採取較輕微之限制手段，即可達企業利益維護之目的，但系爭約定範圍過度寬鬆擴張，致過度侵害勞工職業自由，難以正當化。是以，A金融集團保密合約禁止不當招攬約定，已影響員工職業自由、工作權或擇業自由，此約定應非適法，應不生效力。考生若能在第（一）子題深入論述，分數皆相當不錯；但若只是點到為止，僅提及A金融集團保密合約禁止不當招攬約定涉及競業禁止，不生效力，成績就較不理想。

大多數考生在第（二）子題的表現較不理想，但仍有部分考生很有體系地論述。系爭「禁止不當招攬約定」涉及範圍雖過度廣泛，但若系爭約定係本於不同目的，例如保障「出售消金業務之契約準備階段的公平性」，確保投標者間之競爭平等，僅適用於競標期間、確保投標者競爭平等，則系爭約定仍有適法之可能。

基此，如針對投標期間，有阻止不正競爭之正當效果，既不會讓事實上成立之勞動關係（A 集團所屬員工與投標者）失之無效，則應認在此特定範圍內，約定本身合法，雖嗣後仍有履行違法之可能性。考生若能很有邏輯地論述相關可能性以及其可能產生之效果，即可獲得相當不錯的成績。